

1501631-11.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2222242/2021 - 01º D.P.

DIADEMA, 2222242 - 01º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeilson Sales Almeida

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

JEISON SALES ALMEIDA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501631-11.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001176

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2222242/2021 - 01º D.P.

DIADEMA, 2222242 - 01º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeilson Sales Almeida

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

JEISON SALES ALMEIDA, qualificado às fls. 05/06, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 12h20, na Rua Montevideu, nº. 100, bairro do Centro, nesta cidade de Diadema, trazia com ele, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 104 embalagens plásticas contendo 47,1g da droga cocaína, 17 embalagens plásticas contendo 4,55g da mesma droga, na forma de crack, e 33 embalagens plásticas contendo 20,69g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 12/13 e laudo de constatação provisória de fls. 15/17, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fl.46/49), o réu foi notificado e citado (fls. 86 e 110), e apresentou defesa preliminar as fls.90/92, através do Defensor Público que lhe foi nomeado, pugnando pela absolvição sumária, sem arrolar testemunhas diversas da Acusação. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 03/12/2021 (fl.95).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga cocaína, em que pese a confissão do réu, que é reincidente, discordando da redução da pena e de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, mais a perda do numerário apreendido, sem apelo liberdade, com a perda dos valores apreendidos.

Já o d. Defensor Público reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, reduzindo a pena ainda que em patamar menor, com sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime mais brando, e possibilidade do acusado recorrer em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl.12/13, nos laudos de constatação e no definitivo (fls. 15/17 e 74/76, respectivamente), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha.

A autoria é incontestada não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais (fls.02/04), estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Montevideu, 100, Jd das Nações, Diadema, local conhecido pelo tráfico de drogas, quando visualizaram um homem trazendo consigo uma bolsa bege. Observaram que o indivíduo não havia percebido suas presenças, razão

pela qual ele continuou no local, vindo a esconder o objeto próximo a um entulho de lixo. Sendo assim, decidiram realizar a abordagem do suspeito. Em poder dele, identificado como Jeison Sales Almeida, ora indiciado, encontraram, em seu bolso, a quantia de R\$ 38,00 em notas; além de 05 pedras de crack. Questionado, num primeiro momento, o indiciado se declarou usuário de drogas. Na sequência, foram até o referido entulho, onde apreenderam a bolsa bege que continha em seu interior: 104 porções de cocaína; 33 de maconha; 17 pedras de crack, bem como a quantia de 47,35 em moedas. Dessa vez, indagado novamente, o indiciado confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, acrescentado que recebe a quantia de R\$ 60,00 para vender as substâncias por um período de 12 horas e que na data de hoje, iniciou-se por volta das 08:00 horas. Diante do exposto, conduziram-no para essa unidade policial.

Sob o crivo do contraditório o policial Thiago Ferrari estavam em patrulhamento na via, no local conhecido como ponto de venda de drogas. Avistaram o réu de costas, com um estojo em mão, escondendo junto a uns entulhos. Aproximaram-se e ele até se assustou. Com ele localizaram dinheiro e umas pedras de crack. Foi até o local e ali apreendeu o estojo com as drogas e dinheiro. Indagado, ele disse ser usuário, mas quando viu que não tinha como fugir da situação, ele confessou estar na venda de drogas e que o dinheiro era da mercancia ilícita. Reconhece o réu, e foi a primeira vez que o viu no local.

Igualmente o policial Gustavo Teixeira respondeu que decidiram ir ao local que é um ponto de venda de drogas conhecido. Notaram o réu de costas para a equipe segurando uma bolsa bege. Suspeitaram que ele seria o indivíduo na pratica do tráfico. Ele a escondeu junto a uns sacos de lixo. Quando ele viu a equipe e não dava mais tempo dele correr, foi detido e revistado. Em seu poder tinham cinco pedras de crack e dinheiro. Ele disse ser usuário de crack. Mas seu parceiro voltou aos entulhos e localizou uma bolsinha com várias drogas e então o réu confessou estar na prática do tráfico. Reconhece o réu e foi a primeira vez que o viu naquela biqueira. Às reperguntas da DPE, disse que na bolsinha tinha crack embalados igual às pedras que estavam com o réu, além de maconha e cocaína.

O réu, em solo policial (fl. 5), respondeu que estava próximo ao local e não estava com o material que dizem ser seu, pois é apenas usuário.

Em juízo o acusado alegou que estava sem serviço e precisava de dinheiro para sua família e acabou caindo nesse e se arrepende. Confessa que estava vendendo as drogas e o dinheiro apreendido era dessas vendas.

Logo, a confissão informal, reiterada sob o crivo do contraditório, que não é prova única pois veio corroborada pelos testemunhos dos milicianos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária.

Ademais, os policiais sempre afirmara que o réu, por eles reconhecido, era quem estava em poder da bolsinha contendo as drogas e quem a escondeu próximo de um entulho, não havendo mais ninguém na rua e mais ninguém foi abordado, tanto que em poder dele haviam pedras de crack, e no interior da bolsa, mais substâncias entorpecentes, dentre elas o crack embalados igualmente, e dinheiro proveniente da traficância, sendo o réu confesso.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares de guardar e ter em depósito, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Afasto tese de estado de necessidade ou de situação de pobreza, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Ressalto que o argumento de que o acusado praticou o crime em razão de precariedade financeira não possui o condão de afastar sua responsabilidade penal, tampouco de reduzir a sua pena. Isto porque não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão. Lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares. Nem por isso se enveredam pelo caminho do crime. Ao contrário: buscam solução para seus problemas financeiros através de trabalho honesto. Assim como admitir a falta de emprego como causa excludente de ilicitude seria legalizar a prática de crimes por todo e qualquer indivíduo que esteja desempregado e em precárias condições econômicas - o que não é aceitável (5ª câmara Criminal do TJ/SC - Processo nº 5004204-68.2020.8.24.0030).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e crack) a quantidade de narcóticos (154 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o dinheiro de venda apreendido (fl. 72/73), são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, assim como a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (154 no total) o que reputo excessivo, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado. Em segunda fase, há a circunstância agravante da reincidência (fl. 36 - condenação por roubo na 1ª Vara Criminal de Diadema) a qual compenso com a atenuante da confissão judicial, que por envolver a personalidade do agente, são igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal" (STJ, REsp n. 1.154.752/RS, 3ª Seção, DJE 4.9.2012), de modo que a pena resta inalterada nesta etapa.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Nem o privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente, ainda que não específico, mas a indicar que faz do crime seu meio de vida, inaplicável a ele a benesse, por expressa vedação legal, que não prevê seja a reincidência específica.

Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018) grifo nosso.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos: objetivo (pena

maior que a permitida); e subjetivo (agente não é primário). Ademais: “Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime.” (TJAP) RT 772/617.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a reincidência do réu e a quantidade de pena, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado. Inclusive ante o disposto no artigo 33, do Código Penal, ante à preponderância da natureza (crack e cocaína) e da quantidade da droga (154 no total), e por não ficar o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional. (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas, por reincidente, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado. Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dj. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dj. 20.03.2013).

No mais, deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de sete meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de

execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra JEISON SALES ALMEIDA, qualificado às fls. 05/06, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, para condená-lo à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora, nos termos da Lei estadual nº 11.608 de 2003.

Decreto a perda de bens e dinheiro apreendidos (fl.11 e 72/73), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa).
Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA